

1501500-67.2021.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria Letícia Pozzi Buassi

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/06/2022

... no sentido de evidenciarem ter o acusado praticado o tráfico ilícito.

Contudo, aponta a Jurisprudência dos Tribunais não ser necessária a prova efetiva do tráfico para a formação do Juízo de certeza, bastando a comprovação pelos elementos que cercam o agente. Confira-se: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

4ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, São José do Rio Preto-SP - cep 15010-070

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501500-67.2021.8.26.0559 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501500-67.2021.8.26.0559

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS DE OLIVEIRA SAMPAIO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juíza de Direito: Dra. Maria Letícia Pozzi Buassi

Vistos.

MATHEUS DE OLIVEIRA SAMPAIO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e no art. 307 do Cód. Penal, combinados na forma do caput do art. 69 do mesmo Código, porque no dia 12 de outubro de 2021, por volta das 17h10min, na Rua Professora Lúcia Maria Gali, 680, nesta cidade e comarca, trazia consigo, guardava e mantinha em depósito, para futura entrega a terceiros, treze porções de "maconha", pesando 137,28g, substância esta entorpecente e determinante de dependência física e psíquica, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além de portar R\$ 90,00.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, atribuiu-se o réu falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio.

Policiais militares, em patrulhamento de rotina, perseguiram e abordaram o réu, que tentou fugir pela via ao perceber a aproximação da viatura, arremessando, durante o trajeto e sobre o telhado de um imóvel, três porções do entorpecente.

Em revista pessoal, localizaram os agentes o dinheiro, ocasião na qual se identificou falsamente réu como "Pedro Henrique Oliveira", a fim de ocultar a

condição de foragido.

Efetuada a busca nas imediações da localização originária do denunciado, policiais encontraram o restante do entorpecente, escondido em um imóvel abandonado.

Oferecida a denúncia foi o réu notificado e apresentou defesa prévia.

Recebida a denúncia designou-se audiência de instrução, na qual foram ouvidas duas testemunhas comuns.

Após, foi interrogado o réu.

Em debate, o representante do Ministério Público, sustentando demonstradas a materialidade dos fatos e a autoria dos delitos, requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia.

A defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição do réu apontando, em suma, insuficiência de provas a delinear os crimes.

É o relatório.

DECIDO.

A materialidade dos fatos vem comprovada por intermédio do auto de exibição e apreensão de fls. 15/16, que revela o encontro do entorpecente e do dinheiro em tela.

Há, ainda, o laudo de constatação de fls. 22/25 e o laudo de exame químico toxicológico de fls. 79/81, concludentes no sentido de se tratar de Tetrahydrocannabinol - THC, a substância encontrada.

A pesquisa de fls. 30/32 aponta a existência de mandado de prisão expedido em face do réu e pendente de cumprimento.

Na fase policial exerceu o réu a prerrogativa constitucional de permanecer calado.

Em Juízo, aduziu o réu não portar tóxico e não ter qualquer vínculo com entorpecente. Falou não ter retornado ao presídio quando beneficiado com saída temporária, motivo que o levou a se apresentar, aos agentes, com nome falso.

Contam os policiais que, em patrulhamento, perseguiram e abordaram o réu na via, após ter entregue um invólucro para o condutor de uma motocicleta, que obteve êxito na fuga, localizando-se, nas vestes do acusado, o dinheiro, ocasião na qual se identificou como "Pedro Henrique Oliveira". Detalharam ter o réu, ao notar a viatura, arremessando três porções do tóxico sobre o telhado de uma residência. Explicaram ainda, os agentes, o encontro do restante da droga em um imóvel abandonado, nas imediações. Para tais testemunhas, admitiu o denunciado a prática do comércio ilícito, bem como a falsa identidade, ante a existência de mandado de prisão pendente de cumprimento.

Vale lembrar que o fato de agentes que participam de diligências serem testemunhas sobre estas, torna o relato apresentado mais rico em detalhes e, por isso, mais digno de fé.

No caso em tela as declarações apresentaram-se de forma harmônica e coesa com o restante da prova, razão pela qual não podem ser desconsideradas, inexistindo qualquer motivo para que quisessem os policiais militares incriminar o réu ou forjar os crimes, até porque trata-se de pessoa desconhecida.

A jurisprudência é uníssona ao reconhecer a validade das declarações prestadas, em juízo, por policiais. Neste sentido o Supremo Tribunal Federal: "o valor do depoimento pessoal dos servidores policiais especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC 73.518/SP, rel. Min. Celso de Mello, DJe 14.03.2011).

Urge consignar ser grande a quantidade de droga apreendida em comparação à condição financeira do réu, que não comprovou relação de emprego, logo, seria imprópria somente a eventual uso, sendo a negociação ou guarda do produto, medida impositiva na situação.

Como não se produziu prova a contrariar o já citado auto de exibição e apreensão, o

tráfico é consequência lógica das provas colhidas.

Dessa forma, verifica-se não existirem apenas indícios de prova, mas sim clareza e harmonia entre elas, no sentido de evidenciarem ter o acusado praticado o tráfico ilícito.

Contudo, aponta a Jurisprudência dos Tribunais não ser necessária a prova efetiva do tráfico para a formação do Juízo de certeza, bastando a comprovação pelos elementos que cercam o agente. Confira-se: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 4. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático probatório amalhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Por essas razões, mostra-se inviável a desclassificação da conduta imputada ao réu, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente, exatamente como verificado nos autos. 5. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. 6. Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" –, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso" (STJ, AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020).

Importa destacar não ter a defesa delineado, de forma cristalina, a apresentação, por agentes, de tóxico não achado na posse do réu, e nem motivo haveria para tanto, posto tratar-se de pessoa desconhecida destas testemunhas. Por isso, tal versão é indigna de crédito.

Além disso, conclui-se, ao contrário do sustentado pela defesa, estarem as provas técnica e testemunhal em perfeita harmonia, revelando-se, com a certeza necessária, ter o réu se atribuído falsa identidade no momento da abordagem policial, fazendo-se presente o elemento subjetivo do tipo, o dolo, acrescido do especial fim de agir por parte do réu, qual seja, alcançar proveito próprio.

Destaco, ainda, ter a mentira do réu recaído sobre fato juridicamente relevante, posto que apta a afastá-lo da responsabilidade penal, na situação em análise, especialmente por ter sido abordado na posse de entorpecentes e existir mandado de prisão.

Convencida da responsabilidade penal do réu, passo a individualizar as penas.

- art. 33, caput, Lei nº 11.343/06: Tendo em vista os elementos norteadores do art. 59 do Cód. Penal, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, por não apresentar maus antecedentes.

Verificada a reincidência (fls. 129/135), incide a circunstância agravante prevista no art. 61, inc. I, do Cód. Penal, razão pela qual elevo a pena em 1/6 (um sexto), o que perfaz 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

- art. 307 do Cód. Penal: Tendo em vista os elementos norteadores do art. 59 do Cód. Penal fixo a pena-base em 3 (três) meses de detenção, por não ostentar maus antecedentes.

Verificada a reincidência (fls. 129/135), incide a circunstância agravante prevista no art. 61, inc. I, do Cód. Penal, que se compensa com a confissão da autoria, circunstância atenuante contida no art. 65, inc. III, "d", do Cód. Penal, permanecendo inalterada a pena.

Com base no caput do art. 69 do Cód. Penal, a pena totaliza 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão; 3 (três) meses de detenção; e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena de reclusão é o fechado (art. 1º, § 1º, da

Lei n.º 11.464/07); e o da pena de detenção é o semiaberto, em razão da reincidência do réu (art. 33, § 3º, do Cód. Penal).

Destaco que quando da fixação do regime inicial de cumprimento da pena, já se observou o período de prisão provisória, nos termos do § 2º do art. 387 do Cód. de Proc. Penal.

O fato de ter o réu respondido encarcerado à instrução do feito não implica, com a prolação desta sentença, na concessão de regime menos gravoso. Neste sentido:

"(...) PENA. DETRAÇÃO. CÔMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA PARA FINS DE DETERMINAÇÃO DO REGIME INICIAL DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - ART. 387, § 2º, DO CPP, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 12.736/12. FIXAÇÃO A SER EFETUADA PONDERANDO-SE CONJUNTAMENTE O QUANTUM DA PENA APLICADA COM AS CONDIÇÕES SUBJETIVAS PREVISTAS NOS ARTS. 33, § 3º E 59 DO CP. ENTENDIMENTO. O merecimento do reeducando integra necessariamente os requisitos para sua promoção de regime, sendo vital à individualização da pena que a promoção não se dê de modo automático, como sugeriria uma interpretação desavisada e superficial da redação do § 2º, do art. 387, do CPP, após a reforma de 2012, mesmo porque tal depende do preenchimento de requisitos tanto objetivos quanto subjetivos. Deve-se ressaltar que a lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o CP e não o CPP. Na medida em que a reforma empreendida pela Lei n. 12.736/2012 não revogou o art. 33, § 3º, do CP, a fixação de regime inicial deve ainda considerar obrigatoriamente se foram ou não preenchidas as condições subjetivas, previstas no art. 59 do mesmo estatuto penal. A posterior progressão de regime vem, ademais, necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada aludida progressão, destaque-se, faz-se necessário que sejam sopesados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa, que é o Magistrado das Execuções Penais, e não o prolator da sentença". (TJSP, Apelação Criminal nº 1500199-27.2019.8.26.0407, Rel. Des. Grassi Neto, 9ª Câmara de Direito Criminal, julgado em 19/11/2020). Ainda: "Descabe, igualmente, pleitear aqui regime prisional mais brando com base na atual redação do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, o que ora se destaca, quer à luz do invocado princípio da suficiência da sanção, quer porque a consideração do tempo de prisão provisória não prescindiria de demonstração cabal de bom comportamento carcerário e de condições subjetivas favoráveis, tal como se exige para a avaliação do cabimento de progressão. Se assim não fosse, ficaria ferida de morte a lógica do sistema penal. E tal demonstração não existe nos autos." (TJSP, Apelação Criminal nº 1500128-92.2021.8.26.0559, Rel. Fátima Gomes, 9ª Câmara de direito Criminal, julgado em 31.03.2022).

Deixo de aplicar o § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, ante a reincidência do réu, conforme previsão legal e entendimento jurisprudencial.

Neste sentido: "(...) Não há como ser aplicada a minorante prevista no § 4º do art. da Lei de Drogas em favor do recorrente, haja vista a vedação legal expressa da concessão dessa benesse aos acusados reincidentes. O reconhecimento da agravante da reincidência, na segunda etapa da dosimetria, não é incompatível com a sua utilização, na terceira fase, para afastar a incidência da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porquanto o referido instituto jurídico é sopesado com finalidades distintas em cada fase de fixação da pena, justamente para se alcançar a justa e correta reprimenda necessária para a reprovação e prevenção do delito perpetrado. Não há falar, portanto, em bis in idem. Precedentes." (STJ, HC 671329/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 15.06.2021).

O valor unitário do dia-multa é o mínimo legal, considerada a situação econômica do acusado (art. 43, caput, da Lei nº 11.343/06).

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e condeno MATHEUS DE OLIVEIRA SAMPAIO, R.G. n.º 57.277.814, a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado; a 3 (três) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão mínima ao dia-multa, por ter infringido o art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e o art. 307 do Cód. Penal, combinados na forma do caput do art. 69 do Cód. Penal.

Não poderá o réu apelar desta sentença em liberdade, nos moldes do art. 1º, § 3º, da Lei nº 11.464/07.

Ainda que assim não fosse, em sendo necessária a prisão no correr da instrução do feito, a prolação desta sentença condenatória apenas reforça os motivos ensejadores do afastamento do réu do convívio social, por garantia da ordem pública.

Recomende-se o réu no presídio onde se encontra, expedindo-se mandado de prisão, se necessário.

A pena pecuniária será atualizada a partir da data do fato, uma vez que a correção monetária não apresenta nenhum plus, mas sim tentativa de reposição do poder aquisitivo da moeda.

Força concluir ainda, que a multa não corrigida perde o caráter aflitivo, tornando inútil a imposição, inatendidas as finalidades da sanção penal de punição, dissuasão e reeducação do delinquente.

Observados o art. 63 da Lei nº 11.343/06 e o art. 91, inc. II, "b", do Cód. Penal, DETERMINO O PERDIMENTO do dinheiro, pois obtido em razão do comércio ilícito, conforme prova colhida. Para tanto, oficie-se ao FUNAD.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e, nos termos do art. 72 da Lei nº 11.343/06, oficie-se à Autoridade Policial para que se destrua a amostra de entorpecente guardada para contraprova.

Custas na forma da Lei nº 11.608/03.

P.R.I.C.

São José do Rio Preto, 21 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA